

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0012653-16.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE LIMA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Rafael Henrique Janela Tamai Rocha**

Vistos, etc...

BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no **artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**, porque, no dia 21 de dezembro de 2016, por volta de 14h45, na Travessa Vinte e Nove de janeiro, altura do nº 01, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, guardava, tinha em depósito e transportava, para fins de mercancia, **22 (vinte e dois) invólucros plásticos contendo cocaína, sob a forma de pó, com peso líquido aproximado de 16,3 gramas, e 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido aproximado de 3,9 gramas,** substâncias, estas, de uso proscriito no Brasil, consoante disposto na Lista F1 e F2 da Portaria nº 344/98, do Ministério da Saúde, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado no bojo do inquérito policial instaurado, por ocasião dos fatos, policiais civis efetuavam diligências visando ao combate do tráfico ilícito de entorpecente, momento em que, ao chegarem ao local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, visualizaram um indivíduo, não identificado, recebendo dinheiro de compradores de drogas, enquanto

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

BRUNO retirava a porção de drogas do interior de um maço de cigarros, entregando-a a um usuário.

Ante a evidência de tráfico de entorpecentes, os policiais se aproximaram, oportunidade em que o outro elemento conseguiu galar fuga na posse do dinheiro oriundo do tráfico, sem ser identificado, sendo detido apenas o acusado na posse do entorpecente referido.

Inquirido, o acusado teria confessado, informalmente, aos policiais civis, a prática da traficância.

O acusado foi preso em flagrante, tendo sido referida prisão regularmente convertida em Prisão Preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante comprovado pelo apenso relativo à comunicação do flagrante.

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação do acusado (fls. 108) para a oferta de defesa prévia e resposta escrita, o que ocorreu a fls. 129/131. Após, foi a denúncia regularmente recebida (fls. 140).

Nesta data, foi realizada a audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, bem como foi o acusado interrogado.

Após, as partes ofertaram alegações finais orais, advindo a presente sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

0012653-16.2016.8.26.0635 - lauda 2


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

De antemão, sobre o **ônus da prova**, entendo oportuna a ponderação de algumas ressalvas que balizarão a conclusão alcançada nesta sentença, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em conformidade com o filtro constitucional.

E, para tanto, soa adequado rememorar, com espeque na lição de **Aury Lopes Júnior**, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, *“entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações”* (Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, pag. 45).

Ocorre que, no processo penal, a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, *“não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência”* (ob. cit.) (Grifei).

Vale dizer, em âmbito penal, considerando a relevância e indisponibilidade da natureza da matéria discutida – liberdade do indivíduo – não existe uma distribuição na produção da prova, pois esta se encontra exclusivamente nas mãos do Ministério Público.

Ainda segundo o escólio do referido professor, *“o que sim podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma assunção de riscos. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa." (Grifo no original) (ob. cit.).

Em outras palavras, "carga é um conceito vinculado à noção de unilateralidade, logo, não passível de distribuição, mas sim de atribuição. No processo penal, a atribuição da carga probatória está nas mãos do acusador, não havendo carga para a defesa e tampouco possibilidade de o juiz auxiliar o MP a liberar-se dela (recusa ao ativismo judicial)" (ob. cit.).

Pode-se falar, portanto, que a defesa assume riscos pela perda de uma chance. "Assim, quando facultado ao réu fazer prova de determinado fato por ele alegado e não há o aproveitamento dessa chance, assume a defesa o risco inerente à perda de uma chance, logo, assunção do risco de uma sentença desfavorável. Exemplo típico é o exercício do direito de silêncio, calcado no nemo tenetur se detegere. Não gera um prejuízo processual, pois não existe uma carga. Contudo, potencializa o risco de uma sentença condenatória. Isso é inegável"(ob. cit.) (Grifei).

A conclusão a que se alcança, portanto, é a de que "não há uma carga para a defesa exatamente porque não se lhe atribui um prejuízo imediato e tampouco possui ela um dever de liberação. A questão desloca-se para a dimensão da assunção do risco pela perda de uma chance de obter a captura psíquica do juiz. O réu que cala assume o risco decorrente da perda da chance de obter o convencimento do juiz da veracidade" (ob. cit.) (Grifei).

Em suma, a necessidade de produção da prova para amparar a condenação do réu repousa unicamente nas mãos da acusação, não havendo que se falar em distribuição de cargas processuais.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Assentadas essas premissas, passo ao crime perquirido.

A **pretensão punitiva estatal** deve ser julgada **procedente**.

Vejamos.

A **materialidade** do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação provisória (fls. 14/16), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 116/118), bem como pela prova oral coligida.

A **autoria**, de igual forma, é inconteste, devendo ser atribuída ao acusado.

Vejamos.

Na **fase inquisitiva**, ao ser **interrogado**, o **acusado** reservou-se no direito constitucional ao silêncio, asseverando que apenas se manifestaria perante a autoridade judiciária (fls. 06).

Em **juízo**, **interrogado** sobre os fatos, o **acusado BRUNO** negou a prática da traficância, asseverando que, na data dos fatos, apenas fumava maconha no local, na companhia de um amigo. Declinou, assim, que, tão logo chegou ao local, acabou por ser abordado pelos policiais civis. Sobre o entorpecente, apreendido, alegou que os policiais civis procuraram pelo local, de modo que levaram um certo lapso de tempo para localiza-lo e imputá-lo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a sua pessoa. Sobre a maconha, que, supostamente estaria consumindo, alegou que os policiais a pegaram, mas não a apresentaram perante a autoridade policial. Negou, aliás, possuir qualquer fato contra os policiais responsáveis por sua prisão. Confirmou, ainda, antecedentes criminais anteriores, pela prática de roubo, inclusive tendo ficado internado junto à Fundação CASA, assim como tendo sido preso. Questionado sobre tatuagens, ademais, confirmou uma **CARPA** na barriga.

A testemunha **FERNANDO DOS SANTOS GUBEREV**, policial civil, ouvido em juízo, declinou que, no dia dos fatos, se encontrava em “Operação Papai-Noel”, visando ao combate de tráfico de drogas, oportunidade em que se deslocou a conhecido ponto de tráfico de drogas, de modo que, logo ao adentrar à via pública, acabou por avistar um indivíduo que parecia receber dinheiro de usuários, de modo que o acusado, ao lado, parecia pegar o entorpecente e repassar aos usuários. Deste modo, deliberou pela abordagem dos meliantes, porém, apenas logrou êxito na detenção do acusado, em posse que quem houve a localização, no interior de um maço de cigarros, retirado de uma lixeira onde a droga era homiziada, cerca de 25 porções de *crack* e 20 porções de cocaína. Inquirido, o acusado acabou por confessar, informalmente, a prática da traficância. Negou, de todo modo, prévio conhecimento em relação ao acusado. Negou, outrossim, a apreensão de qualquer valor monetário com o mesmo. Acerca do lapso de tempo da campana velada, destacou cerca de dez a quinze minutos.

A testemunha **FRANCISCO EGÍDIO FERREIRA DE ANDRADE**, policial civil, ouvido em juízo, declinou que, no dia dos fatos, se encontrava em operação policial visando ao combate de tráfico de drogas, oportunidade em que se deslocou a conhecido ponto de tráfico de drogas, de modo que, logo ao adentrar à via pública, acabou por avistar um indivíduo que parecia receber dinheiro de usuários, de modo que o acusado, ao lado, parecia


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pegar o entorpecente, junto a uma lixeira, e repassar aos usuários. Deste modo, deliberou pela abordagem dos meliantes, porém, apenas logrou êxito na detenção do acusado, em posse que quem houve a localização, no interior de um maço de cigarros, de cerca de 25 porções de *crack* e 20 porções de cocaína. Inquirido, o acusado acabou por confessar, informalmente, a prática da traficância. Negou, de todo modo, prévio conhecimento em relação ao acusado. Negou, outrossim, a apreensão de qualquer valor monetário com o mesmo. Acerca do lapso de tempo da campana velada, destacou cerca de vinte minutos, tendo visualizado de dois a quatro usuários.

Conforme se percebe dos depoimentos suso transcritos, **certa é a autoria delitiva do acusado BRUNO**, na medida em que os depoimentos dos policiais civis que atenderam à ocorrência foram uníssomos no sentido de ter sido o acusado surpreendido, em regular operação policial, em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, na posse de elevada quantidade de entorpecente, do tipo cocaína e maconha, em porções individualizadas e aptas à pronta venda. Destaque-se, por oportuno, que a quantidade de droga apreendida não se presta ao reconhecimento do porte para uso próprio, posto que não se trata, em hipótese alguma, consoante ressaltado, de quantidade irrisória **(22 (vinte e dois) invólucros plásticos contendo cocaína, sob a forma de pó, com peso líquido aproximado de 16,3 gramas, e 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido aproximado de 3,9 gramas).**

Além do mais, a existência de cocaína e maconha, em porções individualizadas e aptas à pronta venda, consoante já asseverado, aliado ao local da prisão (conhecido ponto de tráfico), estão a indicar, claramente, a posse para fins de mercancia, até mesmo porque, o **valor de mercado da droga seria ao redor de R\$ 470,00 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)**, valor, este, incompatível para aquisição, para uso próprio, de alguém que se intitulou



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

desempregado, na fase policial, e pintor predial, em juízo.

Aliás, é de se ressaltar que nada há nos autos que possa demonstrar que teriam os policiais agido em contrariedade à lei, “*plantando*” drogas com o acusado, pelo bel-prazer de vê-lo processado, na medida em que se demonstrou que os mesmos sequer a conheciam anteriormente aos fatos.

Ora, atenta à inteligência humana a alegação de que policiais poderiam colocar suas carreiras em risco pelo simples prazer de imputar a alguém a prática de ilícitos de que os sabem inocentes.

É de se concluir, portanto, que a quantidade apreendida de droga, aliada às circunstâncias fáticas, bem como aos relatos dos milicianos, revela a inexorável traficância.

É importante ressaltar que, como é cediço, a utilização do depoimento de policiais como meio probatório é amplamente aceito pela jurisprudência pátria, conforme se conclui pelo julgado que se transcreve, *in verbis*:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MUTATIO LIBELI. ART. 384, CAPUT, DO CPP. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO. PROVAS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

PRECEDENTES MATÉRIA RESERVADA À APRECIÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. 1. O princípio da correlação visa assegurar a ampla defesa, em nada impedindo que diante de circunstâncias fáticas novas, surgidas na instrução processual, sob o crivo do contraditório, modifique-se a imputação dada ao agir do acusado. 2. Na espécie, o Magistrado reconheceu existir elementar da conduta imputada ao acusado, não contida na denúncia, que não agravava sua pena e, em perfeita observância ao art. 384, caput, do Código de Processo Penal, abriu prazo para a Defesa manifestar-se, não havendo falar em aditamento da denúncia. 3. A alegada nulidade do julgamento, feito com base exclusiva nas provas do inquérito, não foi debatida no acórdão recorrido ou, tampouco, foi objeto de embargos declaratórios, carecendo a matéria do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. 4. O que pretende o Recorrente, ao alegar violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, é demonstrar provada sua inocência, sob o argumento de que a confissão do co-réu o inocentou, e também sob a alegação de não serem válidos os depoimentos dos policiais civis. 5. Entretanto, a verificação da procedência de tal alegação implica, necessariamente, no reexame da matéria fático-probatória constante dos autos, impossível na via



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n.º 07 do STJ. Tal pedido, acrescente-se, deve ser reservado ao ajuizamento de revisão criminal perante o Tribunal a quo. 6. Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, Resp nº 604.815/BA, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/08/2005, v.u.).

Ressalte-se não haver, nos autos, qualquer fato que possa desabonar a conduta dos policiais responsáveis pela prisão do acusado.

O simples fato do acusado fazer uso de drogas não leva, inexoravelmente à **desclassificação** do crime hediondo para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, nem mesmo para aquele previsto no artigo 33, § 3º, do mesmo diploma normativo, posto que tal fato não lhe retira a possibilidade de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, consoante amplamente reconhecido pela Jurisprudência.

Ademais, é de se ressaltar que o acusado, em momento algum, confirmou o uso de todo o entorpecente apreendido, o que enfraquece qualquer tentativa de desclassificação da conduta para o disposto no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

artigo 28 e no § 3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, certo é, ainda, que, pela diversidade e quantidade de droga apreendida, a alegação de porte para uso próprio se torna inócua e fantasiosa.

Aliás, para elucidar a questão relativa à quantidade de droga, os juristas **Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio** trazem um parâmetro que define pequena ou grande quantidade da droga, *in verbis*:

"Lembre-mos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, página 114).

Ademais, apenas a título de informação, ainda, é necessário ter em mente que a dose considerada letal para o consumo de cocaína, segundo Pharmacopéia Brasileira e Americana, é de 200 (duzentos) miligramas, o que afasta, por si só, a alegação de porte para uso (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), assim como a aquisição da droga para consumo conjunto com terceiros, ainda que sem o intuito de lucro (artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06).

Afasta-se, ademais, a tese defensiva que alega


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inexistir tráfico, sem a figura do comprador, posto que é cristalino que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, prevê diversos tipos verbais para os quais a figura do comprador de entorpecentes é dispensável, como *in casu*, cuja acusação se circunscreve aos tipos verbais *trazer consigo* e *guardar*, com fins de mercancia, elevada quantidade de entorpecente.

Assim, reconhecidas **autoria** e **materialidade** do crime de **tráfico de substâncias entorpecentes** imputado aos acusados, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Atendendo ao **método trifásico** de aplicação da pena, passo a fixá-la.

Na **primeira fase**, atento às circunstâncias do **artigo 59 do Código Penal**, quais sejam, **culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade** do agente, **motivos, circunstâncias e consequências** do crime, bem como **comportamento da vítima**, conjugadas com as circunstâncias previstas no **artigo 42 da Lei nº 11.343/06** (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com **preponderância** sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a **natureza** e a **quantidade** da substância ou do produto, a **personalidade** e a **conduta social** do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado não deva ser fixada no mínimo legal.

Vejamos.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ao discorrer sobre o tema, assevera, *in verbis*:

“Trata-se de um processo judicial de

0012653-16.2016.8.26.0635 - lauda 12


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...) Tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, de modo a alterar essa conduta ainda predominante" (In Código Penal Comentado, RT, 2010, 10ª Edição, p. 393 e 395).

No mesmo sentido já se manifestou, recentemente, a **Dra. Milena Dias**, Juíza de Direito da 2ª Vara do Júri da Comarca de Santo André/SP, *in verbis*:


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade todos os elementos que dizem respeito ao fato e ao criminoso, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e equilibrada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime. Deve o Magistrado, atrelado a regras de majoração da pena, aumentá-la até o montante que considerar correto, tendo em vista as circunstâncias peculiares de cada caso, desde que o faça fundamentadamente e dentro dos parâmetros legais. A sociedade, atualmente, espera que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima, de modo a ajustar o quantum da sanção e a sua modalidade de acordo com a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima” (Sentença do Processo nº 554.01.2008.038755-7).

Elaboradas as premissas, portanto, passo à individualização da pena nesta **primeira fase**, tendo por parâmetro o **artigo 59 do Código Penal conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06**.

No tocante aos **antecedentes** do acusado, verifica-se que o mesmo possui vida *ante acta* totalmente maculada, já tendo sido condenado, anteriormente, pela prática de roubo, embora referida condenação seja utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, já que demonstrativa de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sua **reincidência**.

No concernente à **conduta social e personalidade** dos agentes, verifica-se a total reprovabilidade de sua conduta, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge população inocente, na maioria das vezes crianças e adolescentes em formação, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras, sem saber como lidar com a drogadição dos filhos.

Como **motivo** do crime, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais mezinhos sentimentos de humanidade e justiça, que objetivou obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do crime, para os usuários e seus familiares é evidente, tratando-se atualmente de um verdadeiro “*câncer*” em nossa sociedade e de difícil combate pelas autoridades públicas.

No tocante à **natureza** e à **quantidade** do entorpecente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, o réu se dedicava à venda de cocaína e *crack*, substância entorpecente, esta, de maior nocividade quando comparada com a maconha, por exemplo.

Afinal, traficar maconha não é a mesma coisa que traficar cocaína ou *crack*.

Ora, a natureza das drogas é completamente diferente e, por isso, sua disseminação entre a população traz diferentes consequências.

O mundo científico é certo em suas ponderações, *in verbis*:


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“O consumo da cocaína, em grande parte dos usuários, aumenta progressivamente, sendo necessário consumir maiores quantidades da substância para se atingir o efeito desejado. Este fenômeno caracteriza o desenvolvimento de um tipo de tolerância à droga, mas de natureza diversa da tolerância observada no uso de álcool e opióides. No caso do crack e da merla, por terem um efeito de curtíssima duração, provocam um uso repetido numa mesma ocasião, sendo mais freqüente que o uso por outras vias de administração. Esse comportamento compulsivo leva o usuário à dependência muito mais rápido que as outras formas de uso de cocaína, e, conseqüentemente, a um custo monetário, de saúde e social muito maiores. A essa compulsão para utilizar a droga repetidamente dá-se o nome popular de “fissura”. Após o uso intenso e repetitivo, o usuário experimenta sensações muito desagradáveis, como cansaço e intensa depressão. A tendência do usuário de cocaína é aumentar a dose da droga na tentativa de sentir efeitos mais intensos. Porém, essas quantidades maiores acabam por levar o usuário a comportamento violento, irritabilidade, tremores e atitudes bizarras devido ao aparecimento de paranóia (chamada entre eles de “nóia”). Esse efeito provoca um grande medo nos usuários, que passam a vigiar o local onde usam a droga e a ter


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

uma grande desconfiança uns dos outros, o que acaba levando-os a situações extremas de agressividade. Eventualmente, podem ter alucinações e delírios. A esse conjunto de sintomas dá-se o nome de “psicose cocaínica”. A libido, também, pode ser afetada entre alguns usuários de cocaína, segundo um estudo do Cebrid, realizado com um grupo de usuários de crack, 60 indivíduos, e outro de cloridrato de cocaína, 42 indivíduos, totalizando 102 participantes. A partir dessa pesquisa percebeu-se que os usuários de cloridrato de cocaína não apresentaram perda de libido. Já os usuários de crack apresentaram uma redução do apetite sexual: 72% das mulheres e 66% dos homens. Os dependentes de cocaína desenvolvem uma sensibilização a alguns efeitos, ou seja, ocorre o inverso da tolerância, e com uma dose pequena os efeitos já surgem. Porém, para angústia dos usuários, esses efeitos sensibilizados são os considerados desagradáveis, como a paranóia e outros efeitos indesejáveis, como agressividade e desconfiança. Não há descrição convincente de uma síndrome de abstinência quando o usuário pára de usar cocaína abruptamente: não sente dores pelo corpo, cólicas ou náuseas. O efeito que se observa é uma grande “fissura”, desejar usar novamente a droga para sentir seus efeitos agradáveis, e não para diminuir ou abolir o sofrimento relacionado à abstinência de algumas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

drogas. Comportamentos de risco estão associados aos usuários de cocaína. Inicialmente, se tinha a idéia de que os usuários da droga injetável estavam mais expostos ao risco de contrair doenças como hepatite, malária, dengue e Aids, pelo compartilhamento de seringa. Porém, o uso da droga por outras vias também gera comportamentos de risco como a prática de sexo desprotegido (sem camisinha), a qual expõe ao contágio pelas doenças citadas, além de outras doenças sexualmente transmissíveis. Um exemplo são algumas mulheres dependentes da cocaína, as quais se prostituem para obter a droga, geralmente sob o efeito da “fissura” o que as faz perder a noção de perigo, não se protegendo nas relações sexuais”. (Fonte: Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – Secretaria Nacional de Combate às Drogas, vinculada ao Ministério da Justiça).

Ademais, é de se ressaltar, ainda, que, *in verbis*:

“Como a cocaína tende a perder sua eficácia ao longo do tempo de uso, fato este denominado tolerância à droga, o usuário tende a utilizar progressivamente doses mais altas buscando obter, de forma incessante e cada vez mais inconsequente, os mesmos efeitos agradáveis que conseguia no início de seu uso. Dosagens muito frequentes e excessivas provocam


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

alucinações táteis, visuais e auditivas; ansiedade, delírios, agressividade, paranoia. Este ciclo torna-o também cada vez mais dependente, fazendo de tudo para conseguir a droga, resultando em problemas sérios não só no que tange à sua saúde, mas também em suas relações interpessoais. Afastamento da família e amigos, e até mesmo comportamentos condenáveis, como participação de furtos ou assaltos para obter a droga são comuns. Além de provocar, em longo prazo, comprometimento dos músculos esqueléticos, existem ainda os agravantes recorrentes da forma de uso. Cocaína injetável, por exemplo, pode provocar a contaminação por doenças infecciosas, como hepatite e AIDS, e infecções locais. No caso daqueles que inalam, comprometimento do olfato, rompimento do septo nasal e complicações respiratórias, estas últimas também típicas dos fumantes, incluindo aí bronquite, tosse persistente e disfunções severas. Gestantes podem ter bebês natimortos, com malformações, ou comprometimento neurológico. Romper com a droga é difícil, já que o indivíduo tende a se sentir deprimido, irritado, e com insônia. Assim, quando um usuário opta por deixá-la, deve receber bastante amparo e ser incentivado neste sentido. É necessária ajuda médica, tanto no processo de desintoxicação quanto tempos depois desta etapa". (artigo escrito por Mariana Araguaia, Graduada em Biologia e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

contido no site do Brasil Escola -
<http://www.brasilecola.com/drogas/cocaina.htm>).

Sobre o *crack*, subproduto da cocaína, a mesma autora pondera, *in verbis*:

“Cerca de cinco vezes mais potente que a cocaína, sendo também relativamente mais barata e acessível que outras drogas, o crack tem sido cada vez mais utilizado, e não somente por pessoas de baixo poder aquisitivo, e carcerários, como há alguns anos. Ele está, hoje, presente em todas as classes sociais e em diversas cidades do país. Assustadoramente, cerca de 600.000 pessoas são dependentes, somente no Brasil. Tal substância faz com que a dopamina, responsável por provocar sensações de prazer, euforia e excitação, permaneça por mais tempo no organismo. Outra faceta da dopamina é a capacidade de provocar sintomas paranoicos, quando se encontra em altas concentrações. Perseguindo esse prazer, o indivíduo tende a utilizar a droga com maior frequência. Com o passar do tempo, o organismo vai ficando tolerante à substância, fazendo com que seja necessário o uso de quantidades maiores da droga para se obter os mesmos efeitos. Apesar dos efeitos paranoicos, que podem durar de horas a poucos dias e pode causar problemas irreparáveis, e dos riscos a que está sujeito; o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

viciado acredita que o prazer provocado pela droga compensa tudo isso. Em pouco tempo, ele virará seu escravo e fará de tudo para tê-la sempre em mãos. A relação dessas pessoas com o crime, por tal motivo, é muito maior do que em relação às outras drogas; e o comportamento violento é um traço típico. Neurônios vão sendo destruídos, e a memória, concentração e autocontrole são nitidamente prejudicados. Cerca de 30% dos usuários perdem a vida em um prazo de cinco anos – ou pela droga em si ou em consequência de seu uso (suicídio, envolvimento em brigas, “prestação de contas” com traficantes, comportamento de risco em busca da droga – como prostituição, etc.). Quanto a este último exemplo, tal comportamento aumenta os riscos de se contrair AIDS e outras DSTs e, como o sistema imunológico dos dependentes se encontra cada vez mais debilitado, as consequências são preocupantes. Superar o vício não é fácil e requer, além de ajuda profissional, muita força de vontade por parte da pessoa, e apoio da família. Há pacientes que ficam internados por muitos meses, mas conseguem se livrar dessa situação”. (artigo escrito por Mariana Araguaia, graduada em Biologia e contido no site do Brasil Escola - <http://www.brasilecola.com/drogas/crack.htm>).

Dessa forma, é incontestável, que a traficância de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

substâncias com maior potencial lesivo, como a cocaína, o *crack*, a heroína e as drogas sintéticas, devam ser mais severamente reprimidos do que a comercialização da maconha, eis que as consequências impostas à saúde da população atingida são diferentes.

No tocante ao *crack*, mais agravada é a situação, posto que seu consumo está vinculado a uma série interminável de outros delitos, muitos dos quais com violência contra a pessoa, dado o grau de vício que atinge, sendo, portanto, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, é de se ressaltar que a quantidade de droga apreendida justifica, por si só, a exacerbação da pena base, já que em montante por demais elevado para a traficância convencional.

Desta forma, à vista da argumentação acima expendida e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base, **1/6 (um sexto)** acima do mínimo legal, isto é, **05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.**

Na **segunda fase**, verifico a incidência da circunstância agravante consistente na **REINCIDÊNCIA do acusado (Execução nº 01 do acusado, relativa a condenação pela prática de Roubo Tentado, pela 3ª Vara Distrital de Ferraz de Vasconcelos/SP, com trânsito em julgado em 17 de agosto de 2012 e término do cumprimento da pena em 14 de setembro de 2013, conforme certidão acostada aos autos, a fls. 157/158)**, motivo pelo qual majoro a pena anteriormente fixada na fração de **1/6 (um sexto)**, perfazendo a pena do acusado o montante de **06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na **terceira fase**, ainda, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem considerada, inclusive a causa de diminuição prevista no **§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06**, posto que, consoante se observou dos autos, o acusado não é primário, mas **REINCIDENTE**, assim como a apreensão de elevadíssima quantidade de entorpecentes demonstra que o acusado esteja intimamente ligado às atividades delituosas.

Deste modo, pois, se chega à conclusão de que o acusado se encontre intimamente envolvido com a traficância, de modo a afastar, por óbvio, a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

É de se destacar, de todo modo, que a aplicação, ou não do redutor, assim como seu percentual, depende da discricionariedade regrada do magistrado, consoante se observa do seguinte aresto, *in verbis*:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2. Não há ilegalidade na aplicação do redutor no percentual de 1/6 (um sexto), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dada a natureza e a grande quantidade de substância entorpecente - 578 (quinhentos e setenta e oito) papелotes de ácido dietilamida lisérgico (LSD) - droga altamente nociva à saúde pública, apreendida com o paciente. 3. Ordem denegada" (STJ, HC 184.579/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 20/10/2011).

Portanto, tenho que a pena da acusada **BRUNO** é fixada, definitivamente, em **06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.**

Entendo que a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, como pleiteia a defesa, em casos como o trazido a julgamento, relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes, não possa prevalecer.

Explico.

O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC. n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli).

Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “esvaziamento” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, o regime inicial de cumprimento de pena ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No caso nos autos, analisando as circunstâncias objetivas da infração cometida, entendo que não seja o caso de fixar regime menos gravoso.

Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, sendo de extrema gravidade, gerando consequências deletérias às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é a mola propulsora de diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, extorsões e latrocínios. Ademais, o tráfico de drogas objetiva, quase sempre crianças e adolescentes, os quais ainda possuem personalidade em formação, acarretando, conseqüentemente, desestruturação de toda uma geração, em evidente prejuízo ao progresso e desenvolvimento sociais.

Aliás, deve ser ressaltado que, ainda que tivesse sido aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 tem-se que isto não implica, inexoravelmente, em direito subjetivo do acusado à fixação de regime menos gravoso, o qual se dá nos termos já esposados, em cotejo com o disposto no artigo 59 do Código Penal (*“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”*) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (*“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”*).

A propósito, nesse sentido a jurisprudência, destacando-se que o segundo argumento continua plenamente válido, *in verbis*:


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar” (TJSP, Apelação nº 0011111-87.2008.8.26.0361, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel: Des. Paulo Rossi, j. 1º/07/2009, grifei).

Portanto, no caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal que não o **REGIME INICIAL FECHADO**, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea a, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo.

Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ressalte-se, ademais, que a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, permite a progressão a criminosos primários que tenham cumprido 2/5 (dois quintos), ou seja, 40% (quarenta por cento) da pena imposta, assim como a progressão a criminosos reincidentes que tenham cumprido 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) da pena imposta, pelo que caberá ao juízo da execução, na oportunidade própria, aferir se o acusado tem condições ou não para a progressão do regime fechado para o semi-aberto.

Ante a gravidade do crime cometido, assim como pelo montante da pena imposta, vislumbrando presentes as circunstâncias previstas no artigo 312 do Código Penal, autorizadoras da prisão preventiva, em especial a necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade da presente sentença.

No sentido exposto, o magistério de **JULIO FABRINI MIRABETE** (Código de Processo penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), *in verbis*:

“O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

E, ainda, nos seguinte julgado, *in verbis*:

“Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado”. (STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.).

Ademais, é irrelevante o fato do acusado ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, consoante já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, *in verbis*:

“LIBERDADE PROVISÓRIA – Benefício pretendido – Primariedade do recorrente – Irrelevância – Gravidade do delito – Preservação do interesse da ordem pública – Constrangimento ilegal inócurrenente.” (In JTJ/Lex 201/275, RSE nº 229.630-3, 2ª Câmara. Crim., rel. Des. Silva Pinto, julg. em 09.06.97).

Ademais, assim já se manifestou o douto Desembargador Caio Eduardo Canguçu de Almeida, recentemente aposentado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, *in verbis*:

“Mas, se um e outro, isto é, se clamor público e necessidade da preservação da respeitabilidade de atuação jurisdicional se


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aliarem à certeza quanto à existência do fato criminoso e a veementes indícios de autoria, claro que todos esses pressupostos somados haverão de servir de bom, seguro e irrecusável fundamento para a excepcionalização da regra constitucional que presumindo a inocência do agente não condenado, não tolera a prisão antecipada do acusado.”

(...)

“Há crimes, na verdade, de elevada gravidade, que, por si só, justificam a prisão, mesmo sem que se vislumbre risco ou perspectiva de reiteração criminosa. E, por aqui, todos haverão de concordar que o delito de que se trata, por sua gravidade e característica chocante, teve incomum repercussão, causou intensa indignação e gerou na população incontrolável e ansiosa expectativa de uma justa contraprestação jurisdicional. A prevenção ao crime exige que a comunidade respeite a lei e a Justiça, delitos havendo, tal como o imputado aos pacientes, cuja gravidade concreta gera abalo tão profundo naquele sentimento, que para o restabelecimento da confiança no império da lei e da Justiça exige uma imediata reação. A falta dela mina essa confiança e serve de estímulo à prática de novas infrações, não sendo razoável, por isso, que acusados por crimes brutais permaneçam livre, sujeitos a uma consequência remota e incerta, como se nada tivessem feito.”

No mesmo sentido, ainda, os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

“RHC – PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PROVISÓRIA – A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem, por si só, a prisão provisória” (STJ, 6ª Turma, v.u., ROHC nº 8566-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, julg. em 30.06.1999).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A existência de indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como a demonstração concreta de sua necessidade, lastreada na ameaça de testemunhas, são suficientes para justificar a decretação da prisão cautelar para garantir a regular instrução criminal, principalmente quando se trata de processo de competência do Tribunal do Júri.

2. Nos processos de competência do Tribunal Popular, a instrução criminal exaure-se definitivamente com o julgamento do plenário (arts. 465 a 478 do CPP).

3. Eventuais condições favoráveis ao paciente – tais como a primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego e residência fixa – não impedem a segregação cautelar, se o decreto prisional está devidamente fundamentado nas hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Nesse sentido: RHC 16.236/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 17/12/04; RHC 16.357/PR, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 9/2/05; e RHC 16.718/MT, de minha relatoria, DJ de 1º/2/05).

4. Ordem denegada. (STJ, 5ª Turma, v.u., HC nº 99071/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julg. em 28.08.2008).

Não se deve perder de mente, ainda, que o acusado respondeu ao processo preso, de forma que, com maior razão, deverá, após a prolação de édito condenatório, deverão permanecer recolhidos, até mesmo para assegurar a execução da pena imposta e a aplicação da lei penal.

Denega-se, pois, o direito ao recurso em liberdade.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Considerada a situação econômica do acusado, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto, **julgo procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de declarar **BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE LIMA**, qualificado nos autos, como **incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-o a cumprir, em estabelecimento penal adequado, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.**

Conforme fundamentado acima, deverá o acusado, iniciar o cumprimento da pena, relativa ao tráfico de entorpecentes, em **regime fechado**, sendo **denegado o direito ao recurso em liberdade**.

Decreto, ainda, nos termos do disposto no **artigo 63 da Lei nº 11.343/06**, a **perda do valor monetário e eventuais objetos apreendidos nos autos, em favor do FUNAD**.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o acusado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, desde já, porém, por ter sido o acusado defendido pela **Defensoria Pública Estadual**, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil Brasileiro, **suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Transitada em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no livro dos culpados.

Para fins do **artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal**, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que o acusado foi preso em 21 de dezembro de 2016, não possuindo, assim, o requisito objetivo-temporal para a progressão no regime, assim como não há demonstração inequívoca de bom comportamento carcerário, demonstrado pelo competente atestado fornecido pelo diretor do estabelecimento prisional em que se encontra custodiados, embora tal atestado pudesse ser solicitado pela defesa e juntado aos autos na presente data.

Expeçam-se as comunicações de praxe, **recomendando-se** o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Oficie-se, ademais, a fim de autorizar a incineração da substância entorpecente apreendida.

Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados.

Registre-se e Cumpra-se.

São Paulo, 29 de março de 2017.

RAFAEL HENRIQUE JANELA TAMAI ROCHA
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**